

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5398/2533

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
เด็กหญิงนนุช บริสุทธิ์ โดยนางบุญรอด
บริสุทธิ์มารดา ผู้แทนโดยชอบธรรม

โจทก์

โจทก์ร่วม

นายสร้อยหรือสัมฤทธิ์ โตแทน

จำเลย

ป.อ. มาตรา 2, มาตรา 3, มาตรา 80, มาตรา 277, มาตรา 279

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

จำเลยต่างขาของโจทก์ร่วมออก ขึ้นคร่อมบนตัวโจทก์ร่วม เอาอวัยวะเพศของตนใส่เข้าไปที่อวัยวะเพศ ของโจทก์ร่วม แต่อวัยวะเพศของจำเลยมิได้ล้วงล้าเข้าไปในช่องคลอด เพราะเยื่อพรหมจารียังปกติดอยู่ แต่ บริเวณปากช่องคลอดและแคมในทั้งสองข้างแดง ผิดปกติ แสดงว่าจำเลยพยายามสอดใส่อวัยวะเพศของตน เข้าไปในช่องคลอดของโจทก์ร่วมแต่กระทำไม่สำเร็จ เพราะมีคนขึ้นมานบนบ้านเสียก่อน พฤติการณ์ป่งชี้ชัดแจ้ง ว่า จำเลยมีเจตนาข่มขืนกระทำชำเรา จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วม ไม่ปรากฏ ว่านอกจากพยายามข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมแล้วจำเลยจะได้กระทำอนาจารอย่างอื่นแก่โจทก์ร่วมอีก จำเลยจึงหามีความผิดฐานกระทำอนาจารโจทก์ร่วมอีกบทหนึ่งด้วยไม่ เมื่อกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด และกฎหมายที่ใช้ภายหลังกระทำความผิดไม่แตกต่างกัน ก็จะต้องปรับบทลงโทษจำเลยตามกฎหมายที่ใช้ใน ขณะกระทำความผิด จะปรับบทลงโทษตามกฎหมายที่ใช้ภายหลังกระทำผิดไม่ได้ การที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทกฎหมายลงโทษจำเลยไม่ถูกต้องนั้น เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน แม้คู่ความจะมีได้ ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา
225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำอนาจารเด็กหญิงนางนุช บริสุทธิ์ผู้เสียหายอายุ 11 ปี
เศษ และพยายามข่มขืน กระทำชำเราผู้เสียหายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 80, 277, 279 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3 จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เด็กหญิงนางนุช บริสุทธิ์ผู้เสียหาย โดย
นางบุญรอด บริสุทธิ์ มารดาผู้แทนโดยชอบธรรม เข้าร่วมเป็นโจทก์

ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
279 จำคุก 5 ปี ข้อหาอื่น

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 277 วรรคสอง, 80พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530มาตรา 3 ด้วย แต่เป็นกรรม เดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ให้ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง, 80 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 3 จำคุก 6 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำของโจทก์ร่วมว่าเมื่อจำเลยถอดกางเกงของโจทก์ร่วมออก และถอดกางเกงของตนแค่หัวเข้าแล้ว จำเลยถ่างขาของโจทก์ร่วมออก และขึ้นคร่อมบนตัวโจทก์ร่วมเอาอวัยวะเพศของตนใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของโจทก์ร่วม แต่อวัยวะเพศของจำเลยมิได้ล้วงล้าเข้าไปในช่องคลอดของโจทก์ร่วมเพราะเยื่อพรหมจารียังปกติดูอยู่แต่บริเวณปากช่องคลอดและแคมในทั้งสองข้างแดงผิปกติ แสดงว่า จำเลยพยายามสอดใส่อวัยวะเพศของตนเข้าไปในช่องคลอดของโจทก์ร่วม แต่กระทำไม่สำเร็จ เพราะมีเสียง สุนัขเห่าและคนขึ้นมาบนบ้านเสียก่อน พฤติการณ์บ่งชี้ชัดแจ้งว่า จำเลยมีเจตนาข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วม จำเลยลงมือกระทำความผิดแล้ว แต่กระทำไปไม่ตลอด จำเลยจึงมีความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเรา โจทก์ร่วมตามฟ้องโจทก์จริง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเรา โจทก์ร่วมชอบแล้ว แต่ที่ปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 เห็นว่า เหตุคดีนี้เกิดเมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2525กฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดคือมาตรา 277 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 แม้ภายหลังจะมีกฎหมายแก้ไขใหม่ เป็นความผิดตามมาตรา 277 วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย อาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดและภายหลังกระทำ ความผิดไม่แตกต่างกัน กรณีก็ต้องปรับบทลงโทษจำเลยตามมาตรา 277 วรรคหนึ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ

ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 อันเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำ ความผิดและที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า จำเลยมีความผิดฐานกระทำอนาจาร โจทก์ร่วมอีกบทหนึ่งด้วยนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่านอกจากพยายามข่มขืนกระทำชำเราโจทก์ร่วมแล้ว จำเลยได้ กระทำอนาจารอย่างอื่นแก่โจทก์ร่วมอีก จำเลยจึงหามีความผิดฐานกระทำอนาจารโจทก์ร่วมอีกบทหนึ่งด้วยไม่ และการที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยไม่ถูกต้องนั้น เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความจะมีได้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 ประกอบด้วยมาตรา 80จำคุก 6 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันท-อัมพร ทองประยูร)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นายบุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายวุฒิชัย ไวยภาพ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ